

的显著性时就不可避免地会将与之相关联的餐饮食品一并考虑在内。就本案而言,“福粿”在泉港当地消费者的认知中已经等同于“浮粿”,浮粿作为泉港本地特色小吃,属于本地餐饮服务提供者通常会提供的菜品,就相关消费者而言,“福粿”作为服务商标使用,导致服务商标与餐饮食品的互相重合,大大削弱了服务商标本身所应具有显著性,对于服务来源的识别作用也丧失殆尽。对于显著性较弱的注册商标而言,其保护力度应当与显著性相适应,特别在与社会公众利益相冲突的情况下,在相关服务项目上更应适当限制其保护范围。

三、认定被诉侵权人对于“福粿”是否正当使用应当考虑商标权人、被诉侵权人对于“福粿”的认知和使用方式以及消费者是否容易发生混淆误认

泉州某公司注册涉案“福粿”商标后,将“福粿◎餐厅”字样印制于名片、点菜单、手提袋、台历、宣传单上,宣传单中介绍泉港当地传统特色小吃时使用的商品名称为“特色福粿”。因此,泉州某公司作为商标注册人,具备将注册商标使用于核定服务项目上的主观意图。同时,泉州某公司亦明知且认同“福粿”系泉港当地传统特色小吃通用名称的属性,并在其餐厅中提供该类菜品。另外,泉州泉港某小吃店在门头招牌上使用“泉港福粿”字样,店铺内以及外卖平台上亦出售与泉州某公司菜单中“特色福粿”相同做法的泉港特色小吃,其使用的商品名称为“福粿”,商品描述为“泉港福粿,有福之粿”。此外,泉州泉港某小吃店还销售波浪薯条、黄金脆鸡排等其他小吃产品。泉州泉港某小吃店上述对于“福粿”的使用方式,显然是将“福粿”作为该类泉港特色小吃的商品名称看待并使用。泉州泉港某小吃店将店铺名称直接描述成主要提供商品的名称,并未单独突出使用“福粿”字样,消费者并不会因此而对餐饮服务的来源产生混淆误认。此外,如果不允许他人将“福粿”作为约定俗成的商品通用名称进行使用,过度保护注册商标权利人,不仅不利于该类小吃及其制作技艺作为非物质文化遗产的推广,也会造成泉州某公司对公共资源的不当垄断,进而损害公共利益。因此泉州某公司虽然是“福粿”注册商标的专用权人,但无权禁止他人正当将“福粿”

作为该类小吃的商品通用名称使用，泉州泉港某小吃店的行为不构成商标侵权。

本案司法裁判生效之后，泉州市中级人民法院指导泉州市泉港区人民法院向涉及非物质文化遗产保护、商标管理、商贸行业管理等职能的主管部门发出司法建议三份，就摸清非物质文化遗产的底数、探索集体商标申请注册、知识产权信息整合共享、非物质文化遗产项目转化等方面提出建议，规范引导辖区企业经营行为。

本案进一步明晰了涉非遗知识产权的权利边界以及注册商标权利限制的适用条件，在文旅经济日益盛行的情况下，判决结果较好地平衡了权利人利益、其他经营者利益以及社会公众利益，有利于地方特色传统小吃的推广及非遗技艺的传承和保护，裁判结果具有正确社会导向及价值取向，实现法律效果和社会效果的统一。

编写人：福建省泉州市中级人民法院 黄熠 黄玮鹏

约定惩罚性赔偿倍数在商标侵权案件中的适用

——甲公司诉桂林市象山区乙酒店侵害
商标权及不正当竞争案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海知识产权法院(2022)沪73民终663号民事判决书

2. 案由：侵害商标权及不正当竞争纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):甲公司

被告(上诉人):桂林市象山区乙酒店(一审时原名称:象山区丙商务酒

店，以下简称乙酒店)

【基本案情】

一、甲公司企业信息、商标注册信息及商标使用情况

甲公司成立于2011年12月9日，为有限责任公司，注册资本2196.445043万元，企业经营范围为酒店管理、以特许经营方式从事商业活动等。原名青岛丁城际酒店管理有限公司，2016年8月更名为青岛甲生活集团有限公司。2022年5月更名为现名称。

甲公司2018年4月27日受让涉案商标：第9××3号“丙”商标，核定服务项目为第43类住所等。注册有效期自2012年2月21日起，目前处于有效期内。2012年2月21日至2022年2月20日甲公司经许可使用该商标。

甲公司在“2013年度中国饭店集团60强”榜单中排在第13名。甲公司在“2016—2018年度中国饭店集团60强”榜单、“2016—2019中国酒店集团规模50强排行榜”榜单，“丙”品牌在“2016—2019中国经济型酒店品牌规模30强”榜单中名列前茅。2019年度甲公司支出的广告宣传费约2748万元。

二、象山区丙商务酒店相关经营信息

象山区丙商务酒店成立于2015年3月12日，系个体工商户，经营范围为住宿服务。经营者为李甲，经营位于桂林市××号的酒店，其提供的2021年10月28日照片显示，涉案酒店已经将“丙”字样全部拆除，更名为“戊酒店”。庭后查看某生活信息及交易平台的页面，“戊酒店(桂林万福广场店)”，地址为桂林市××号，“设施/详情”页显示，酒店2017年开业。页面评论区有多条早于2017年的网友评论，最早的评论为2015年。2022年6月28日，名称由“象山区丙商务酒店”变更为“桂林市象山区乙酒店”。

三、被控侵权情况

2020年12月10日，甲公司通过可信时间戳保存了象山区丙商务酒店所经营的酒店照片，店招、楼层标识、前台、广告牌、房间内的牙具、洗浴用品、电话均标识“丙商务酒店”，并获得一张60元的发票。

2020年12月31日，甲公司通过可信时间戳保存了某生活信息及交易平台

APP 内象山区丙商务酒店店铺的信息, 名称为“桂林象山区丙商务酒店”, “2018年开业”“50间客房”, 地址“桂林市x×号”, 房价118元至197元不等。网友评价的配图中部分图片与甲公司取证的图片显示标识一致。

四、双方在先合同情况

2012年9月7日, 甲公司作为甲方与李甲作为乙方签订了《丁城际酒店管理有限公司商标授权使用管理合同》(以下简称《管理合同》), 约定乙方位于广西桂林象山区××号的房屋开展“某商务宾馆”经营, 合同期限自2012年9月7日至2022年9月6日。乙方有权合法使用“丁”商标、标识。自乙方开始营业时起, 乙方按宾馆当月营业收入的3.5%的标准向甲方缴纳商标许可使用费。合同第十三章约定了合同终止(解除)后的承诺, 第13.6条约定, 如果乙方违反本承诺, 在合同终止后仍然使用甲方商标或者软件等, 乙方自愿按本合同约定的费用标准的5倍向甲方支付使用费(实施费); 不能如期归还相关资料的, 每份文件(手册)乙方向甲方赔偿人民币伍仟元整。合同第十六章补充约定载明“本酒店为象山区丙商务酒店加盟项目”。

2015年8月4日, 李甲向甲公司提出《丙城际酒店桂林平山店关于解除与丁城际酒店管理有限公司合作的申请报告》(以下简称《申请报告》), 称该店于2015年4月开始, 面对巨大的经营压力每天亏损2000元左右, 故提出解约申请。

2015年8月31日, 甲公司与李甲达成《解约协议》, 于当日解除前述《管理合同》, 约定自本协议签订之日起, 甲方终止乙方对“丙”商标的使用许可, 若乙方擅自继续使用, 或存在其他侵犯甲方商标权的侵权行为, 甲方有权依法追究相关责任人的法律责任。协议附件中列明了有关解除《管理合同》乙方需要更改的项目, 包括招牌、吧台、走廊、房间内物品、卫生间卫浴产品等均不得带有甲方标识。

甲公司认为象山区丙商务酒店属于恶意侵犯商标专用权, 且情节严重, 应当适用惩罚性赔偿。象山区丙商务酒店擅自将与甲公司的“丙”商标相同的“丙”文字作为其企业名称的字号使用并持续至今, 用于经营住宿服务, 构成不正当竞争。

【案件焦点】

1. 象山区丙商务酒店的涉案行为是否构成商标侵权；2. 象山区丙商务酒店涉案行为是否构成不正当竞争；3. 是否应对被告适用惩罚性赔偿。

【法院裁判要旨】

上海市浦东新区人民法院经审理认为：

一、关于象山区丙商务酒店的涉案行为是否构成商标侵权

甲公司系第9××3号“丙”注册商标专用权人，有权就侵害上述商标的行为主张权利。象山区丙商务酒店在线上、线下经营活动中使用“丙”标识起到了识别服务来源的作用，属于商标性使用。象山区丙商务酒店在酒店店招、市内装潢、房间电器、洗浴用品上使用了“丙”标识，与甲公司商标核定类别相同，相关标识与甲公司商标构成近似，容易导致消费者对商品和服务来源产生混淆，构成商标侵权。象山区丙商务酒店实施了商标侵权行为，应当承担停止侵害、赔偿损失的民事责任。

二、关于象山区丙商务酒店涉案行为是否构成不正当竞争

2012年2月，第3x×4号“丙”商标即获得注册，核定使用服务为第43类的住所等。甲公司主张根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条第四项认定被告行为构成不正当竞争。法院认为，该商标与象山区丙商务酒店提供的服务类别相同，象山区丙商务酒店将该注册商标作为企业名称中的字号使用，没有正当理由。象山区丙商务酒店攀附甲公司商誉的恶意明显，客观上误导相关公众，足以使相关公众误以为其与甲公司存在特定联系，构成不正当竞争。象山区丙商务酒店应就其企业名称进行更名。

三、关于是否应对被告适用惩罚性赔偿

（一）关于侵权主观故意

对于被告的故意的认定，应当综合考虑被侵权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系，且接触过被侵害的知识产权的，可以认定被告具有侵害知识产权的故意。本案中，

象山区丙商务酒店个体工商户的经营者早在2012年即与甲公司签署《管理合同》，经授权开展“丙”酒店经营。象山区丙商务酒店对开展的酒店业务的品牌予以否认，但未能提供相应证据。结合《申请报告》《解约协议》足以认定象山区丙商务酒店曾作为被授权方接触过甲公司注册商标，反映出象山区丙商务酒店具有明显的侵权故意，可认定象山区丙商务酒店恶意侵犯商标专用权。

（二）关于侵权情节

对于侵权情节严重的认定，应当综合考虑侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素。被告成立于2015年，在某生活信息及交易平台的页面显示涉案酒店2018年成立，房间数50间，双方确认涉案侵权标识于2021年10月拆除，象山区丙商务酒店侵权行为持续时间较长，侵权规模较大，侵权获利巨大，符合侵犯商标专用权的情节严重的要件。

（三）关于基数和倍数确定

本案中，双方在先签订有《管理合同》，权利人因侵权所受到的实际损失可参考双方约定的商标许可使用费计算。《管理合同》中约定商标许可使用费自乙方开始营业时起，按宾馆当月营业收入的3.5%的标准缴纳商标许可使用费。合同终止（解除）后的承诺，第13.6条约定，如果乙方违反本承诺，在合同终止后仍然使用甲方商标或者软件等，乙方自愿按本合同约定的费用标准的5倍向甲方支付使用费。双方的上述约定，可视为对于商标侵权惩罚性赔偿基数和倍数的约定，并不违反法律规定，可以作为确定惩罚性赔偿金额时的重要参考因素。被告称宾馆经营持续亏损，但未提供宾馆经营的相关账簿、资料，法院参考相关行业客房的平均入住率计算涉案酒店的营业收入，计算公式为“房间总数×平均入住率×平均客房单价×经营时间”。

1. 关于房间总数。象山区丙商务酒店在某生活信息及交易平台页面上自行标注50间房间，虽在庭审中称仅有48间，但未提供证据证明，应以其对外公示的50间作为计算基数。

2. 关于平均入住率。甲公司提供了上海某国际酒店股份有限公司、北京某

酒店(集团)股份有限公司2020年度报告的平均出租率为55%—60%。被告自称的入住率在40%以下。法院结合酒店规模、品牌、地域等因素并综合考虑多种因素,确定涉案酒店的平均入住率为40%。

3. 关于平均客房单价。某生活信息及交易平台显示全天房价118元到197元,甲公司称取证时入住的为钟点房,票据显示60元。综合考虑各类房型入住比例,法院确定平均客房单价为80元。

4. 关于经营时间。象山区丙商务酒店在某生活信息及交易平台上展示的开业时间为2018年,象山区丙商务酒店陈述自2018年8月起开业,但未提供证据。甲公司主张象山区丙商务酒店自2015年起即营业。结合庭后查看更名之后的“戊酒店”页面情况,显示开业时间又为2017年,说明某生活信息及交易平台酒店页面的信息可由被告自行修改,网友评论区最早有2015年的评论,足可认定被告自2015年起即开始经营涉案酒店,而双方解约的时间点为2015年8月31日,故可确定被控侵权行为的持续时间为2015年9月1日至2021年10月27日。

综上,涉案侵权行为惩罚性赔偿的基数应当为 $50 \times 40\% \times 80 \times 2248 \times 3.5\% = 125888$ 元,结合双方在《管理合同》中约定的倍数,最终确定被控侵权行为的赔偿金额为629440元。

上海市浦东新区人民法院依据《中华人民共和国商标法》第四条第二款、第四十八条、第五十七条第二项、第五十八条、第六十三条第一款,《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条第四项,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第三款,《中华人民共和国民法典》第一百二十三条第一款、第二款第三项,第一百七十九条第一款第一项及第八项、第二款、第三款,第一千一百八十五条,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条、第十二条、第十七条,《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第一条,第三条第一款、第二款第三项,第四条第一款、第二款第五项,第五条第一款、第二款,第六条第一款之规定,判决如下:

一、象山区丙商务酒店于判决生效之日起十日内赔偿甲公司经济损失629440元及为制止侵权所支出的合理开支10000元，共计639440元；

二、象山区丙商务酒店于判决生效之日起停止不正当竞争行为，并于判决生效之日起三十日内变更企业名称，变更后的企业名称中不得含有与“丙”相同或近似字样；

三、驳回甲公司其余诉讼请求。

乙酒店(原象山区丙商务酒店)不服一审判决，提起上诉。

上海知识产权法院同意一审法院裁判意见，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一、约定惩罚性赔偿的可行性和必要性分析

(一)现行法律依据

约定赔偿作为知识产权损害赔偿方式中较为特殊的一类，散见于各司法解释中。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十八条、《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十五条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条均规定，当事人按侵权人侵权获利或权利人实际损失就赔偿数额达成协议的，法院应当允许。司法实践中，《北京市高级人民法院关于侵害知识产权及不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见及法定赔偿的裁判标准》第1.21条也对此进行了明确。尽管上述司法解释中均未明确可就惩罚性赔偿进行约定，但是惩罚性赔偿作为损害赔偿计算的一种方式，理应涵盖在上述司法解释可约定的范围内。

(二)遏制侵权的现实需要

司法实践中，知识产权侵权案件适用法定赔偿的比例仍然较高，知识产权权利人在面对侵权行为特别是初次发现侵权行为时，主张惩罚性赔偿需要满足法定的相应条件方可认定侵权故意和情节严重的要件，获得支持

的难度较大，通过传统的知识产权维权模式对于侵权行为的预防和阻遏作用有限。而无论是

